

1001428-94.2020.8.26.0326
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Dano ao Erário
Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI
Comarca: Lucélia
Foro: Foro de Lucélia
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 14/10/2022

... nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagli Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).
O caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lucélia
Foro de Lucélia
1ª Vara
Praça José Firpo, s/nº, . - Centro
CEP: 17780-000 - Lucélia - SP
Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia1@tjsp.jus.br

1001428-94.2020.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1001428-94.2020.8.26.0326
Classe - Assunto
Ação Civil Pública - Dano ao Erário
Requerente e Litisconsorte Ativo:
Ministério Público do Estado de São Paulo e outro
Requerido:
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

1. RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO, em face de CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, CÍNTIA REGINA RICARDO, FONTAINE TAZINAZZO BASTOS, SONIA APARECIDA GUARDIANO, JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES, BARBARA CABRAL ROSAL, BARBARA CABRAL ROSAL ME e JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Em suma, acusa os requeridos de terem praticado violações à Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), configuradoras de condutas tipificadas na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), consistentes em direcionar contratações a determinadas empresas ou prestadores de serviços de sua preferência, destacando-se, além dos que constituem objeto da presente ação, fatos que estão sendo apurados em outros inquéritos civis e policiais que tramitam nesta Comarca. Descreve a inicial que, no dia 12 de abril de 2018, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 2935/000, tomou, sem licitação, os serviços da firma JOMAR

SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, tendo por objeto a manutenção da área verde do Parque Veneza e de toda área verde no Salto Botelho, mediante o pagamento da importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Ocorre que tal contratação, além de eivada de má-fé, não poderia ter sido feita, uma vez que a contratada tem como sócios a requerida SONIA APARECIDA GUARDIANO e seu companheiro JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES, sendo ela servidora pública municipal e membro da Equipe de Apoio nos Pregões do Município, conforme Portaria Municipal nº 238, de 22 de maio de 2018, já que a Lei Orgânica Municipal de Lucélia proíbe o ente público de contratar com servidor público ou com pessoas a ele aparentadas. O responsável por atestar a execução desses serviços foi o requerido FONTAINE TAZINAZZO BASTOS, então Secretário Municipal de Meio Ambiente. A requerida CINTIA REGINA RICARDO, Secretária de Administração do Município, autorizou o respectivo pagamento (FATO 1).

Menciona também que, no dia 31 de outubro de 2018, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 9648/000, tomou, sem licitação, os serviços da firma JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, tendo por objeto a prestação de serviços necessário para a manutenção e conservação no telhado e no banheiro da estação cultural, mediante o pagamento da importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ocorre que tal contratação, além de eivada de má-fé, não poderia ter sido feita, uma vez que a contratada tem como sócios a requerida SONIA APARECIDA GUARDIANO e seu companheiro JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES, sendo ela servidora pública municipal e membro da Equipe de Apoio nos Pregões do Município, conforme Portaria Municipal nº 238, de 22 de maio de 2018, já que a Lei Orgânica Municipal de Lucélia proíbe o ente público de contratar com servidor público ou com pessoas a ele aparentadas. Além da ilegalidade acima apontada em tal contratação, embora insistentemente solicitado a comprovar a efetiva prestação dos serviços pagos, o requerido JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES não logrou fazê-lo (FATO 2).

Narra, ainda, que no dia 28 de dezembro de 2018 (e 07 de janeiro de 2019), a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 11843/000, tomou, sem licitação, os serviços da firma JOMAR SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, tendo por objeto a realização de obras para acabamento ao redor da piscina municipal, mediante o pagamento da importância de R\$ 24.560,07 (vinte quatro mil e quinhentos e sessenta reais e sete centavos) procedendo a contratação com os mesmos vícios já apontados. Ocorre que tal contratação, além de eivada de má-fé, não poderia ter sido feita, uma vez que a contratada tem como sócios a requerida SONIA APARECIDA GUARDIANO e seu companheiro JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES, sendo ela servidora pública municipal e membro da Equipe de Apoio nos Pregões do Município, conforme Portaria Municipal nº 238, de 22 de maio de 2018, já que a Lei Orgânica Municipal de Lucélia proíbe o ente público de contratar com servidor público ou com pessoas a ele aparentadas. Também, o requerido JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES não teria comprovado a execução do serviço (FATO 3).

Seguindo, no dia 18 de abril de 2019, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 3430/000, contratou novamente a empresa JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, tendo por objeto a realização de obras de adequação no prédio do transbordo municipal, mediante o pagamento da importância de R\$ 32.987,00 (trinta dois mil, novecentos e oitenta sete reais) procedendo a contratação com os mesmos vícios já apontados. Ocorre que tal contratação, além de eivada de má-fé, não poderia ter sido feita, uma vez que a contratada tem como sócios a requerida SONIA APARECIDA GUARDIANO e seu companheiro JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES, sendo ela servidora pública municipal e membro da Equipe de Apoio nos Pregões do Município, conforme Portaria Municipal nº 238, de 22 de maio de 2018, já que a Lei Orgânica Municipal de Lucélia proíbe o ente público de contratar com servidor público ou com pessoas a ele aparentadas. Reiteradamente, o requerido JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES não teria comprovado a execução do serviço (FATO 4).

Por fim, consta que no dia 29 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante nota de

empenho nº 2773/000, contratou a empresa BARBARA CABRAL ROSAL ME, tendo por objeto a realização de obras de construção/adequação de elevações transversais (quebra molas), em varias vias do Município, pelo valor de R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), padecendo a contratação de vício de legalidade. A contratação de BARBARA CABRAL ROSAL visou apenas a fazer entrega de dinheiro público a ela. E isso porque sua inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas teria ocorrido no dia 25 de março de 2019. Já no dia seguinte, BARBARA CABRAL ROSAL teria apresentado na prefeitura o orçamento de fl. 231, propondo-se a realizar os serviços pela importância de R\$ 7.950,00. No dia 29 de março, foi emitida a nota de empenho respectiva. No dia 02 de abril, foi emitida a nota fiscal de serviços e atestada sua execução. No 05 de abril, a requerida CINTIA REGINA RICARDO autorizou a realização da despesa e no dia 08 de abril, foi feito o pagamento a BARBARA CABRAL ROSAL.

Ocorre que a requerida não executou os serviços pelos quais recebeu. Sequer tinha condições de fazê-lo. Simplesmente repassou a execução a Celso Del Vecchio, pagando-lhe a importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em dinheiro, e embolsando a diferença de R\$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme esclareceram BARBARA à fl. 107 (Doc. 13) e Celso Del Vecchio à fl. 223 (Doc. 20) e fl. 241 do IP (Doc. 21). (fato 5).

Em suma, de acordo com o Ministério Público, teriam os requeridos CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, CÍNTIA REGINA RICARDO, FONTAINE TAZINAZZO BASTOS e SONIA APARECIDA GUARDIANO, agentes políticos e servidora pública, respectivamente, se ajustado para realizar ou permitir as contratações direcionadas a empresas e pessoas de sua preferência, concorrendo para a apropriação de verbas públicas, implicando violação aos preceitos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 e artigo 63, §§ 1º e 2º da Lei 4.320/1964, no que tange aos deveres de legalidade, probidade e lealdade ao Município e do artigo 10, inciso XII, da Lei nº 8.429/92, causando dano ao erário.

Já aos requeridos JOSÉ CARLOS SIMÕES RODRIGUES, BÁRBARA CABRAL ROSAL, BÁRBARA CABRAL ROSAL 43599374821 - ME e JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA., embora não sendo agentes públicos, que teriam concorrido e se beneficiaram da prática dos atos ilícitos, sendo-lhes aplicáveis as disposições e sanções previstas na Lei nº 8.429/92, com espeque no artigo 3º da referida lei. Ainda, evocou o artigo 101 da Lei Orgânica Municipal que proíbe os agentes públicos de contratarem com pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco.

Pugna, ao final, pela procedência do pedido para condenar os requeridos na prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, especialmente descrito no inciso XII e artigo 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/92, impondo-se a eles as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da mesma Lei.

Com a inicial (fls. 01/21), juntou documentos (fls. 22/464), especialmente o laudo confeccionado pelo Instituto de Criminalística de fls. 206/242.

Foi determinada a notificação prévia dos servidores públicos e intimação da Fazenda Pública para integrar a lide, nos termos do artigo 17, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, vigente à época dos fatos (fls. 465/466).

Regulamente notificado (fl. 477), o réu FONTAINE TAZINAZZO BASTOS apresentou manifestação escrita às fls. 490/499. Direto ao mérito, alegou a inexistência de ato de improbidade, aduzindo que: a) com relação à nota de empenho nº 2935/000, de 12/04/2018, não estava investido no cargo de Secretário do Meio Ambiente; ademais, referida nota teve sua autorização adstrita à Secretaria de Administração. Informa que era Diretor do Setor de Meio Ambiente, mas foi exonerado em 01/03/2018, sendo nomeado Secretário do Meio Ambiente em 01/06/2018, conforme Decretos Municipais nº 8.516 e 8.563, de 2018; b) em relação à nota de empenho 11843/000, indicou que o setor responsável (Secretaria de Desenvolvimento) é diverso de sua secretaria (do Meio Ambiente), e novamente, a nota teve sua autorização cancelada pela Secretaria de Administração, não havendo qualquer envolvimento no seu empenho e execução, sendo o serviço acompanhado por pessoa diversa.

Juntou procuração e documentos (fls. 500/503).

Notificados (fls. 485, 487 e 489), os réus SONIA APARECIDA GUARDIANO, JOMAR SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS de CONSTRUÇÃO LTDA., bem como seu titular JOSE

CARLOS SIMÕES RODRIGUES, apresentaram manifestação por escrito às fls. 504/565. Preliminarmente, arguíram a inépcia da inicial por inadequação da via eleita. No mérito, em suma, bateram-se pela legalidade nas contratações, já que, na hipótese, a licitação era dispensada. Acrescentaram que os serviços prestados não se referiram a parcelas de um mesma obra ou serviço, ou de mesma natureza, respeitando o limite percentual da lei para a dispensa da licitação na modalidade convite. Que os serviços contratados foram todos executados e atenderam aos valores de mercado. Por fim, rechaçou o artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, considerando a dispensa da licitação.

Juntaram procuração e documentos (fls. 566/726).

BARBARA CABRAL ROSAL ME., bem como sua titular Barbara Cabral Rosal, notificadas à fl. 823, apresentaram defesa preliminar às fls. 755/760. Direto ao mérito, alegam ausência de qualquer irregularidade, já que o registro da pessoa jurídica ocorreu para atender aos ditames da lei; praticou-se contratação direta, respeitando-se os limites dos artigos 23 e 24 da Lei de Licitações; e que os serviços contratados foram todos executados e atenderam aos valores de mercado.

Juntaram procuração e documentos (fls. 761/773).

CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, regularmente notificado à fl. 483, apresentou manifestação às fls. 774/794. Preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva aduzindo não ter tido envolvimento com os fatos imputados e requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, discorreu sobre a legalidade das contratações, já que realizadas de forma direta, atendidos os percentuais exigidos por lei. Rechaçou também a aplicação do artigo 101 da Lei Orgânica, já que não houve qualquer participação de SÔNIA, enquanto servidora pública, consoante a modalidade de contratação. Diz que os serviços foram todos executados. Por fim, que não há falar em dolo genérico e que não houve qualquer prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.

Juntou procuração e declaração de pobreza (fls. 795/825 e 796).

Determinou-se a intimação do corréu retro mencionado para juntada de documentos, com o fim de comprovar sua condição de hipossuficiência. Não obstante, quedou-se inerte (fls. 818/819 e 826).

Regulamente notificada (fl. 481), a ré CINTIA REGINA RICARDO, apresentou defesa preliminar fls. 797/815. Arguiu preliminar de inépcia da inicial e requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, no mesmo sentido da peça anterior, bateu-se pela legalidade das contratações, já que contratadas de forma direta, atendido os percentuais exigidos por lei. Rechaçou também a aplicação do artigo 101 da Lei Orgânica, já que não houve qualquer participação sua no processo licitatório, enquanto servidora pública, consoante a modalidade de contratação direta. Que os serviços foram todos executados. Por fim, que não praticou qualquer dolo ou concorreu para prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.

Juntou procuração e declaração de pobreza (fls. 816/817).

Manifestação do Ministério Público às fls. 838/859, repisando os termos da exordial.

A inicial foi recebida pela decisão de fls. 860/864, ocasião em que foram afastadas as preliminares arguidas pelos demandados e determinada a citação dos acusados.

Os requeridos foram citados às fls. 875/876.

BARBARA CABRAL ROSAL ME e BARBARA CABRAL ROSAL ofertaram contestação às fls. 884/889; SONIA APARECIDA GUARDIANO, JOMAR SERVIÇOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES às fls. 893/969; CINTIA REGINA RICARDO às fls. 1033/1073; CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR às fls. 1074/1118 e FONTAINE TAZINAZZO BASTOS às fls. 1119/1133, reiterando, todos, as alegações de suas respectivas manifestações preliminares.

O Ministério Público apresentou réplica às fls. 1139/1160.

Determinada a especificação de provas por despacho de fl. 1162, SONIA APARECIDA GUARDIANO, JOMAR SERVIÇOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e JOSE CARLOS SIMÕES RODRIGUES requereram a produção de prova oral (fls. 1166/1169); BARBARA CABRAL ROSAL ME e BARBARA CABRAL ROSAL nada requereram, pugnando pelo julgamento antecipado (fl. 1172); FONTAINE TAZINAZZO BASTOS requereu depoimentos e oitivas,

além da juntada de novos documentos (fls. 1175/1176). Por fim, CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR e CÍNTIA REGINA RICARDO requereram depoimentos e oitivas às fls. 1177/1178.

O Parquet requereu a colheita dos depoimentos pessoais dos requeridos e a oitivas de testemunhas (fls. 1173/1174).

Pela decisão de fl. 1179: a) rejeitaram-se as preliminares; b) deferiu-se o requerimento de expedição de ofício ao Município de Lucélia para juntada de cópia do processo de sindicância correlato; e c) concederam-se os benefícios da AJG à requerida Cíntia Regina Ricardo.

A Fazenda Pública do Município de Lucélia juntou procuração e cópia do processo de sindicância às fls. 1184/2633.

Designou-se audiência de instrução (fls. 2649/2651).

Por decisão de fl. 2756, rejeitou-se o pedido de extinção prematura do feito pela aplicação retroativa das mudanças levadas a cabo pela Lei nº. 14.230/2021.

Em audiência, foi inquirida a testemunha José Carlos Rotoli, sendo determinado o compartilhamento de provas quanto aos demais depoimentos e oitivas, extraídos da ação penal n.º 1500902-07.2019.8.26.0326 (2761/2764).

Declarada encerrada a instrução, as partes ofertaram alegações finais.

Às fls. 2797/2824, reiterou o Ministério Público os termos da exordial. Demais memoriais às fls. 2773/2776; 2825; 2829/2946; 2948/2988; 2992/3026 e 3027/3031.

É o relatório do essencial.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Partes legítimas e bem representadas, encontrando-se presentes as condições da ação, bem como os pressupostos de desenvolvimento válido e regular da formação processual.

De proêmio, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, visto que não comprovada sua hipossuficiência por meio de provas documentais.

As questões preliminares já foram robustamente rejeitadas por meio da decisão saneadora.

No mérito, o pedido é improcedente.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, submetida ao procedimento da Lei n. 8.429/92.

Considerando a complexidade do tema, realizo, inicialmente, uma breve explanação sobre o conceito de improbidade, sua natureza jurídica e requisitos legais para sua caracterização.

2.1. Conceito de improbidade

Adverte Fernanda Marinela que o termo “probidade” deriva do latim “probus” que traduz a ideia daquilo que é bom, virtuoso, honrado, ético e honesto. Falar em improbidade, portanto, é falar em desvio de valores e de conduta.

Ocorre que nem todo desvio é objeto da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92).

Para fins da LIA, ser ímprobo é abusar do poder que é conferido a alguém ou a si mesmo em razão do exercício de uma função pública, com a finalidade de tirar proveito para si ou para outrem, causando prejuízo relevante ao bem comum, ainda que disso não decorra dano ao erário. Ou seja, trata-se de uma desonestidade que viola o regime administrativo e os princípios correlatos.

Prossegue a doutrina esclarecendo que podemos definir improbidade administrativa como uma desonestidade (1) que se apresenta sob a forma de ilegalidade/imoralidade; (2) revestida de má-fé; (3) mas também corrupta e interesseira; (4) além de nociva à ordem social.

Assim, “improbidade administrativa” é expressão técnica atrelada à corrupção administrativa, ao desvio de conduta, falta de retidão e desobediência aos princípios éticos, podendo acarretar enriquecimento ilícito do agente e dano ao

patrimônio público.

Em outros termos, improbidade administrativa é o ato de desrespeito, por parte do agente público (ou terceiro a ele vinculado), ao dever a ele imposto de agir com honestidade no exercício do cargo público que ocupa, sem que se aproveite indevidamente dos poderes e facilidades que deste decorrem, quer seja para exclusivo proveito pessoal, quer seja para benefício de outrem.

2.2. Fonte normativa

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988 é a fonte normativa base da improbidade administrativa no Brasil, notadamente, mas não só, seu art. 37, que prevê:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

No campo legal, ficou a cargo da Lei n. 8.429/92 (LIA) regulamentar a matéria. Trata-se de norma de âmbito nacional à exceção de certos dispositivos que vinculam exclusivamente a União.

2.3. Natureza jurídica

Esclarece a doutrina que a Lei n. 8.429/92 trata a improbidade administrativa como um ilícito de natureza civil e política, entendimento este endossado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2797).

Não obstante, todo ato de improbidade administrativa também se configura como um ilícito administrativo, punido de acordo com o estatuto funcional do agente público ímprobo.

No Estado de São Paulo, por exemplo, de acordo com o disposto no art. 257, inciso XIII, da Lei Estadual n. 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado) ao servidor que praticar ato de improbidade será aplicada a pena de demissão.

Ainda, a depender da imoralidade cometida, o ato de improbidade poderá também ser responsabilizado na órbita penal, desde que, logicamente, esteja previsto como figura penalmente típica, em respeito ao princípio da legalidade dos delitos e das penas.

É por isso que o art. 12 da LIA dispõe que as sanções por ele previstas serão aplicadas independentemente das punições de natureza civil, administrativa e penal previstas na legislação específica.

Em outras palavras, o ato ímprobo pode (e deve) ser coibido em todas as esferas de responsabilização, de forma independente, não havendo falar em "bis in idem". Excepcionalmente, haverá comunicação entre as instâncias se, no processo penal, ocorrer absolvição por comprovação da inexistência do fato ou por negativa de autoria.

2.4. Dos elementos que compõem o ato de improbidade administrativa

Para a configuração da improbidade administrativa é preciso que se afigurem os seguintes elementos no caso concreto:

(i) Sujeito ativo

É o agente público e eventual particular, pessoa física ou jurídica, envolvido(s) na prática da conduta ilícita, nos termos dos artigos 2º e 3º da LIA, com redação dada pela Lei nº. 14.230/2021:
Confira-se:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade.

Veja-se que, desde que o agente público e o terceiro estejam unidos para praticar o mesmo ato, com o mesmo fim e unidade de desígnios, ambos responderão pela improbidade. Assim, particulares, sem qualquer vinculação com o Poder Público, respondem por atos de improbidade se induzirem, concorrerem ou se beneficiarem do ato.

(ii) Sujeito passivo

São as entidades enumeradas pela LIA:

Art. 1º.

[...]

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

(iii) Prática de uma conduta típica no exercício ou em razão da função pública

O sujeito ativo deve ter cometido um dos comportamentos descritos nos artigos 9º (atos que importam enriquecimento ilícito), 10 (atos que causam prejuízo ao Erário) ou 11 (atos que atentam contra os princípios da Administração Pública), por ação ou omissão, no exercício ou em razão da função pública.

Trata-se de tipos abertos e descritivos, restando claro que o legislador não teve a pretensão de exaurir o campo das possibilidades para o reconhecimento de um ato ímprobo. O rol das condutas é, assim, meramente exemplificativo.

De destacar que o comportamento ímprobo tentado não é punido pela lei. Isso porque os atos de improbidade são todos qualificados pelo resultado, de modo que, ausente o efetivo enriquecimento ilícito, o concreto dano ao erário ou a real violação aos princípios da Administração, não haverá falar em punição.

a) Art. 9º, LIA

Os atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito, previstos no art. 9º

da Lei n. 8.429/1992, referem-se à obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º da LIA.

Para sua configuração, desnecessário que ocorra prejuízo ao Erário, bastando o recebimento da vantagem indevida pelo agente.

Nessa toada:

“Ainda que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei n. 8.429/1992), excluindo-se, contudo, a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário. Isso porque, comprovada a ilegalidade na conduta do agente, bem como a presença do dolo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, a ausência de dano ao patrimônio público exclui tão-somente a possibilidade de condenação na pena de ressarcimento ao erário. As demais penalidades são, em tese, compatíveis com os atos de improbidade tipificados no art. 9º da LIA” (STJ. Corte Especial. REsp 1.412.214-PR. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves. Julgado em: 08/03/2016. DJe: 28/03/2016).

b) Artigos 10, LIA

Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário, consagrados no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, relacionam-se à ação ou omissão, agora exclusivamente dolosa, que acarreta perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública e demais entidades mencionadas no art. 1º da LIA.

Para sua consumação, imprescindível a efetiva lesão ao erário, sendo irrelevante eventual enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro.

c) Art. 11, LIA

Constitui ato de improbidade administrativa a conduta, comissiva ou omissiva dolosa, que contraria os princípios da Administração Pública, em desconformidade com os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, na forma do art. 11 da LIA.

Aqui, eventual inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário não afasta a configuração do ato de improbidade, uma vez que a doutrina e a jurisprudência se contentam com a violação dos princípios que regem a Administração Pública, posição materializada pelo § 4º do art. 11.

O “dano” aqui é contra a honestidade, boa-fé, lealdade e imparcialidade que se esperam do agente público.

De acordo com os §§ 1º a 4º do mencionado art. 11, somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado, na conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Ainda, imperiosa a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas, bem como a comprovação de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

(iv) Presença do elemento subjetivo

Em outubro de 2021, foi publicada a Lei nº 14.230, que alterou significativamente a Lei nº 8.429/92, trazendo acentuadas inovações.

Com a atual sistemática trazida pela nova lei, a configuração de atos de improbidade administrativa passa a depender de inequívoca comprovação de dolo específico do sujeito, afastando-se da esfera de punição a modalidade culposa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 909446, “a má-fé torna-se premissa do ato ilegal e ímprobo: a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica ferir os princípios constitucionais da Administração Pública e se somar à má intenção do administrador”.

Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE LANCHES MATINAIS. DOLO NÃO CONFIGURADO. SUCESSIVA RENOVAÇÃO DO CONTRATO MOTIVADA EM FACE DAS PECULIARIDADES DO OBJETO LICITADO. 1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011 REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/9/2010; REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/6/2010. (STJ. 1ª Turma. REsp 1192056/DF. Rel. Ministro Teori Albino Zavascki. Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em: 17/04/2012. DJe: 26/09/2012).

Logo, faz-se necessário que a conduta típica esteja acompanhada de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa. De acordo com o art. 1º, § 2º, LIA, com redação dada pela Lei nº. 14.230/2021, "Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Verifica-se, assim, que, a teor do que estabelece a Lei de Improbidade Administrativa, optou o legislador ordinário pela consagração da responsabilidade subjetiva do servidor público, exigindo-se a presença do dolo nas três espécies de atos de improbidade elencados nos arts. 9º, 10 e 11.

Nessa linha intelectual, é possível afirmar que o enquadramento da conduta do sujeito ativo como ato de improbidade exige a averiguação de atuação dolosa, afastando-se a figura da responsabilização objetiva ou mesmo da culpa.

(v) Dano

Por fim, para a configuração do ato de improbidade, necessária a ocorrência de prejuízo, que não necessita ser de ordem patrimonial ou econômica, podendo ser moral, intelectual etc.

Nas palavras do Pretório Excelso, "na maioria das vezes, a lesividade ao erário público decorre da própria ilegalidade do ato impugnado" (RE 160381-SP).

Situação diversa se verificará no caso específico dos atos ímprobos previstos no artigos 10, LIA, para os quais é imprescindível a comprovação de efetivo dano ao patrimônio público, sob pena de não configuração.

Nessa linha:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, XIII, DA LEI N. 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO CULPA E NECESSIDADE DE DANO AO ERÁRIO. 1. [...]. 2. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário), com exceção da conduta do art. 10, VIII, exige-se a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa. Precedentes. [...]. (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1542025-MG. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. DJe: 12.06.2018).

2.5. Das sanções cominadas pela lei

O art. 37, § 4º, da CRFB/88, estabelece que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
Preceito regulamentar da disposição constitucional acima referida, o art. 12 da Lei n. 8.429/1992 enuncia:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

§ 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.

§ 2º A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos I, II e III do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade.

§ 3º Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades.

§ 4º Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no § 3º deste artigo.

§ 5º No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta Lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo.

§ 6º Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta Lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos.

[...]

§ 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

[...]

Verifica-se, assim, em um primeiro momento, que as sanções previstas pela LIA podem

ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Enquadrando-se o fato típico em mais de uma modalidade, serão observadas as disposições da infração mais grave (nesta ordem de grandeza: art. 9º, 10 e 11). Ainda, a aplicação das sanções independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, nos casos correlatos (art. 21, II, LIA).

2.6. Direito Intertemporal

Necessário consignar, que, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, após afetar o ARE 843989 como leading case, fixou as seguintes teses no que toca à aplicação das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92 (Tema 1199):

- 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLLO;
- 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
- 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de sua revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
- 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

O julgamento sedimenta o entendimento da Corte Maior de Justiça a respeito da aplicação retroativa da Lei nº. 14.230/2021, encerrando a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.

Nessa ordem de ideias, é certo que a resolução do mérito no caso concreto dependerá da análise da presença de dolo específico em conjugação com a lesão ao erário. Ausentes qualquer um desses pressupostos, a pretensão não poderá subsistir. Realizada digressão sobre os elementos que compõem o ato de improbidade e as sanções correspondentes, passo à análise do caso concreto.

3. Das imputações

Na exordial, o Parquet imputa as seguintes condutas aos requeridos:

- (a) no período de abril de 2018 a abril de 2019, nesta cidade e Comarca de Lucélia, CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, CINTIA REGINA RICARDO, FONTAINE TAZINAZZO BASTOS, SONIA APARECIDA GUARDIANO, JOSÉ CARLOS SIMÕES RODRIGUES e BÁRBARA CABRAL ROSAL associaram-se para o fim específico de direcionamento de contratações da Prefeitura Municipal de Lucélia, em favor de determinadas empresas ou prestadores de serviços de sua preferência.
- (b) na data de 12 de abril de 2018, a Prefeitura Municipal de Lucélia, por meio de seu então Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 2935/000, processo nº 01392/000-2018, contratou, sem licitação, os serviços da empresa JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA., tendo por objeto a manutenção da área verde do Parque Veneza e de toda área verde no Salto Botelho, mediante o pagamento da importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Ocorre que tal contratação, além de eivada de má-fé, não poderia ter sido feita, uma vez que a contratada tem, como sócios, SONIA APARECIDA GUARDIANO e seu convivente JOSÉ CARLOS SIMÕES RODRIGUES (págs. 28), sendo ela servidora pública municipal e membro da Equipe de Apoio nos Pregões do Município, conforme Portaria Municipal nº 238, de 22 de maio de 2018, já que a Lei Orgânica do Município de Lucélia proíbe o Município de contratar com servidor público ou com pessoa a ele aparentada.

(c) no dia 31 de outubro de 2018, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu então Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 9648/000, processo de compra 04775/000-2018, contratou, sem licitação, os serviços da mesma firma, JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA., tendo por objeto a prestação de serviço necessário para a manutenção e conservação no telhado e no banheiro da estação cultural, mediante o pagamento da importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

No mesmo sentido esposado, tal contratação não poderia ter sido feita, uma vez que a contratada tem como sócios a denunciada SONIA APARECIDA GUARDIANO e seu convivente, também denunciado, JOSÉ CARLOS SIMÕES RODRIGUES, sendo ela servidora pública municipal e membro da Equipe de Apoio nos Pregões do Município, já que, conforme esclarecido, a Lei Orgânica do Município de Lucélia proíbe o Município de contratar com servidor público ou com pessoa com ele aparentada.

(d) no dia 28 de dezembro de 2018 (pagamento em 07 de janeiro de 2019), a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu então Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 11843/000, pedido de compra nº 05962/000-2018, contratou sem licitação a mesma empresa JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA., tendo por objeto a realização de obras para acabamento ao redor da piscina municipal, mediante o pagamento da importância de R\$ 24.560,07 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e sete centavos), padecendo a contratação dos mesmos vícios já apontados.

(e) no dia 18 de abril de 2019, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu então Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 3430/000, pedido nº 01734/000-2019, contratou novamente a mesma empresa JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA., tendo por objeto a realização de obras de adequação no prédio do transbordo municipal, mediante o pagamento da importância de R\$ 32.987,00 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais), conforme empenho nº 3430/2019, padecendo a contratação dos mesmos vícios já apontados.

(f) no dia 29 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Lucélia, através de seu então Prefeito CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, mediante a nota de empenho nº 2773/000, pedido nº 01296/000-2019, contratou a empresa BÁRBARA CABRAL ROSAL 43599374821 - ME, tendo por objeto a realização de obras de construção/adequação de elevações transversais (quebra-molas), em várias vias do Município, pelo valor de R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), também padecendo a contratação de vício de legalidade, sendo manifesto o direcionamento em seu favor.

Em suma, os requeridos CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR, CÍNTIA REGINA RICARDO, FONTAINE TAZINAZZO BASTOS e SONIA APARECIDA GUARDIANO, agentes políticos e servidora pública, respectivamente, teriam se ajustado para realizar ou permitir contratações direcionadas a empresas e pessoas de sua preferência, concorrendo para a apropriação de verbas públicas, implicando violação aos preceitos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 e artigo 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 4.320/1964, no que tange aos deveres de legalidade, probidade e de lealdade ao Município; ao artigo 10, e seu inciso XII, da Lei nº 8.429/92, causando dano ao erário.

Já os requeridos JOSÉ CARLOS SIMÕES RODRIGUES, BÁRBARA CABRAL ROSAL, BÁRBARA CABRAL ROSAL ME e JOMAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA., embora não sendo agentes públicos, teriam concorrido e se beneficiado da prática dos atos ilícitos, sendo-lhes aplicáveis as disposições e sanções previstas na Lei nº 8.429/92, com espeque no art. 3º da mesma lei.

Ainda, evocou o artigo 101 da Lei Orgânica Municipal que proíbe os agentes públicos de contratarem com pessoas ligadas a estes por matrimônio ou parentesco.

Pois bem.

4. Do mérito

Conforme escólio de José Afonso da Silva, "a probidade administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito

a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p. 669).

A improbidade administrativa pode ser definida como "a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagli Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).

O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

A responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator.

De acordo com o sistema processual de distribuição do ônus da prova, cumpria ao autor demonstrar, de forma contundente, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o enriquecimento ilícito dos requeridos, os prejuízos ao erário e a afronta a princípios que regem a Administração Pública, em observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste diapasão, Humberto Theodoro Júnior leciona, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz" (...) "Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual". (...) Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 12ª ed., Ed. Forense, p. 419/420).

Prevê a Lei n. 4.320/1964, em seu artigo 63:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá

por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

O não atendimento às diretrizes supracitadas na Lei do Orçamento implicaria, em tese, violação ao preceito legal previsto no artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/1992.

Nessa linha, assevera o Ministério Público que os requeridos infringiram a LIA, já que os serviços objetos das notas de empenho nº 2935/000, processo nº 01392/000-2018 (fl. 55), nº 9648/000, processo de compra 04775/000-2018 (fl. 56), nº 11843/000, pedido de compra nº 05962/000-2018 (fl. 57), nº 3430/000, pedido nº 01734/000-2019 (fl. 58), nº 2773/000, pedido nº 01296/000-2019 (fl. 62) não teriam sido executados pelas empresas contratadas.

Ocorre que tal fato não respondeu demonstrado nos autos.

Extraí-se do laudo pericial do Instituto de Criminalística n.º 376.042/2019, fls. 207/242:

“Nota de empenho nº. 2935/000 (...)

A-) SERVIÇOS PRESTADOS NO CLUBE DE CAMPO SALTO BOTELHO:

(...)

CONCLUSÃO:

Tendo em vista a data da emissão da Nota Fiscal 12/04/2018 e a data da vistoria 08/10/2019, o relator não pode precisar se os serviços foram executados. Se os serviços foram realmente realizados, provavelmente foram executados entre o mês de março e abril de 2018.

B-) SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA VERDE DO PARQUE VENEZA:

(...)

CONCLUSÃO:

Tendo em vista a data da emissão da Nota Fiscal 12/04/2018 e a data da vistoria 08/10/2019, o relator não pode precisar se os serviços foram realmente executados nesta data. Se os serviços foram realmente realizados, provavelmente foram executados entre o mês de março e abril de 2018”.

“Nota de empenho nº. 9648/000 (...)

A-) SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO CULTURAL, CONSERVAÇÃO DO TELHADO:

(...)

CONCLUSÃO:

Realmente, a cobertura